

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3615/2548

พนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
นายมงคล คมขำ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 3, มาตรา 59 วรรคสอง, มาตรา 59 วรรคสาม

ป.วิ.อ. มาตรา 92 (เดิม) (2), มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 223, มาตรา 225,
มาตรา 226

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15, มาตรา 66

พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 มาตรา 8, มาตรา 15 วรรคหนึ่ง,
มาตรา วรรคสาม (2), มาตรา 66 วรรคสอง

เจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมและสายลับล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลยทั้งสามในบ้านที่เกิดเหตุ ซึ่งสามารถล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนได้ แม้เจ้าพนักงานตำรวจจะมีได้ดำเนินการขอหมายค้นจากศาลชั้นต้นไปตรวจค้นบ้านที่เกิดเหตุ ก็หาเป็นข้อพิรุธของพยานโจทก์ในการตรวจค้นจับกุมไม่ เพราะเป็นกรณีกระทำความผิดซึ่งหน้าที่กำลังกระทำลงในที่รโหฐานจึงตรวจค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นตาม ป.วิ.อ. มาตรา 92 (2) (เดิม) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะเกิดเหตุ

แม้คดีนี้เจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมจะใช้อุบายล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลยทั้งสาม ก็มีใช้กรณีที่เจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมเป็นผู้ชักจูงใจหรือก่อให้เกิดสามกระทำความผิดฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน เพราะจำเลยทั้งสามมีเจตนาร่วมกันกระทำความผิดอยู่ก่อนแล้ว การล่อซื้อของพยานโจทก์ดังกล่าวเป็นเพียงการแสวงหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความผิดของจำเลยทั้งสาม เมื่อจำเลยทั้งสามร่วมกัน

จำหน่ายเมทแอมเฟตามีนให้แก่เจ้าพนักงานตำรวจ การกระทำของจำเลยทั้งสาม
ย่อมเป็นความผิดฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน อันเป็นความผิดสำเร็จ หาใช่ว่าเมื่อมี
การใช้อุบายวางแผนล่อซื้อต้องถือว่าขาดเจตนาซื้อขายกันจริง จึงไม่มีความผิดฐาน
จำหน่ายเมทแอมเฟตามีนไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา
15 และมาตรา 66 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะจำเลยทั้งสามกระทำความผิด
แต่ปรากฏว่าในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้มี พ.ร.บ.ยาเสพติดให้
โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 8 และมาตรา 19 ยกเลิกความในมาตรา 15 และ
มาตรา 66 แห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และให้ใช้ข้อความใหม่แทนโดย
ในความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายคดีนี้ มีองค์ประกอบ
ความผิดตามมาตรา 15 วรรคสาม (2) ที่แก้ไขใหม่ ไม่เป็นคุณแก่จำเลยจึงต้องใช้
กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง เดิม มาใช้บังคับแก่คดีนี้ และ
ความผิดฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง ที่แก้ไขใหม่ มีองค์
ประกอบความผิดเช่นเดียวกับมาตรา 15 วรรคหนึ่ง เดิม จึงต้องใช้กฎหมายเดิมซึ่ง
ใช้ในขณะกระทำความผิดมาบังคับแก่คดีนี้เช่นเดียวกัน ส่วนในมาตรา 66 วรรคสอง
ที่แก้ไขใหม่ ซึ่งเป็นบทระวางโทษของความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบ
ครองเพื่อจำหน่ายและฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนสำหรับเมทแอมเฟตามีนอันเป็น
วัตถุแห่งการกระทำความผิดที่มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 375 มิลลิกรัม
ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 กรัม แม้จะปรากฏว่าเมทแอมเฟตามีนของกลางคดีนี้มีจำนวน
46 เม็ด และมีน้ำหนักสุทธิเกินกว่า 1.5 กรัม ก็ตาม แต่ตามคำฟ้องไม่ปรากฏว่า เมท
แอมเฟตามีนของกลางอันเป็นองค์ประกอบความผิด คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้
จำนวนเท่าใดกันแน่ จึงไม่อาจปรับบทลงโทษจำเลยตามมาตรา 66 วรรคสอง ที่
แก้ไขใหม่ได้ แต่ต้องถือว่าการกระทำของจำเลยยังมีความผิดอันต้องด้วยบท
ระวางโทษตามมาตรา 66 วรรคหนึ่ง ที่แก้ไขใหม่อยู่ ซึ่งตามมาตรา 66 วรรคหนึ่ง ที่

แก้ไขใหม่ ในส่วนของโทษจำคุกมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 15 ปี แตกต่างจาก มาตรา 66 วรรคหนึ่ง เดิม ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึงจำคุกตลอดชีวิต กฎหมายที่แก้ไขใหม่ในส่วนนี้เป็นคุณแก่จำเลยที่ 1 มากกว่ากฎหมายเดิม จึงต้องใช้ กฎหมายที่แก้ไขใหม่ดังกล่าวในส่วนที่เป็นคุณมาบังคับแก้คดีนี้ตาม ป.อ. มาตรา 3 ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 1 ยังมีได้ยกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขให้ถูกต้อง จำเลยที่ 1 ย่อมมีสิทธิยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกา ได้ แม้ว่าจะเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วแต่ในศาลอุทธรณ์ภาค 1 ก็ตาม ทั้งนี้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225 ศาลฎีกาจึงต้องแก้ไขโดย ปรับบทลงโทษจำเลยที่ 1 ให้ถูกต้อง และเห็นสมควรแก้ไขกำหนดโทษจำคุกจำเลยที่ 1 เสียใหม่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบทกฎหมายที่แก้ไขใหม่ตามที่จำเลยที่ 1 ฎีกา ด้วย และเนื่องจากจำเลยทั้งสามเป็นตัวการกระทำความผิดในคดีนี้ด้วยกัน ถือว่าเหตุ ดังกล่าวเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจพิพากษาแก้ไขตลอดไป ถึง จำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งมีได้ฎีกาได้ด้วยตาม ป.วิ.อ. มาตรา 213 ประกอบมาตรา 225

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 102 ป.อ. มาตรา 83, 91 ริมเมทแอมเฟตามีนของกลาง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีน ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและฐานร่วมกันจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 66 วรรคหนึ่ง ป.อ. มาตรา 83

เป็นความผิดหลายกรรมให้เรียงกระทงลงโทษตาม ป.อ. มาตรา 91 ฐาน (ร่วมกัน) มี
เมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุกคนละ 6 ปี ฐาน (ร่วมกัน)
จำหน่ายเมทแอมเฟตามีน จำคุกคนละ 5 ปี รวมเป็นจำคุกคนละ 11 ปี ริบเมทแอม
เฟตามีนของกลาง

จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษา
ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอถอนฎีกา ศาลฎีกา
อนุญาตและมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 ออกจากสารบบความของศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม้คดีนี้ร้อยตำรวจเอกธีรยุทธกับพวกจะล่อซื้อเมทแอมเฟ
ตามีนจากจำเลยที่บ้านที่เกิดเหตุโดยมิได้ดำเนินการขอหมายค้นจากศาลชั้นต้นไป
ตรวจค้นบ้านที่เกิดเหตุ ก็หาเป็นข้อพิรุทธของพยานโจทก์ไม่ เพราะร้อยตำรวจเอกธี
รยุทธกับพวกอาจเล็งเห็นได้ว่าจะล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลยทั้งสามเป็นผล
สำเร็จ อันเป็นกรณีกระทำความผิดซึ่งหน้าที่กำลังกระทำลงในที่รื้อฐานจึงตรวจค้น
ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีหมายค้นตาม ป.วิ.อ. มาตรา 92 (2) เดิมซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้
บังคับในขณะเกิดเหตุ

แม้คดีนี้ร้อยตำรวจเอกธีรยุทธและสิบตำรวจตรียุทธศักดิ์พยานโจทก์จะใช้อุบาย
ล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนของกลางจากจำเลยทั้งสาม ก็ไม่ใช่กรณีที่พยานโจทก์ดั่ง
กล่าวเป็นผู้ชักจูงใจหรือก่อให้เกิดจำเลยทั้งสามกระทำความผิดฐานจำหน่ายเมทแอมเฟ
ตามีน เพราะจำเลยทั้งสามมีเจตนาร่วมกันกระทำความผิดอยู่ก่อนแล้ว การล่อซื้อ

ของพยานโจทก์ดังกล่าวเป็นเพียงการแสวงหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความผิดของจำเลยทั้งสามเท่านั้น เมื่อจำเลยทั้งสามร่วมกันจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนจำนวน 20 เม็ด ให้แก่สืบตำรวจตรียุทธศักดิ์ การกระทำของจำเลยทั้งสามย่อมเป็นความผิดฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน อันเป็นความผิดสำเร็จ

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 และมาตรา 66 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะจำเลยทั้งสามกระทำความผิด แต่ปรากฏว่าในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้มี พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 8 และมาตรา 19 ยกเลิกความในมาตรา 15 และมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และให้ใช้ข้อความใหม่แทนโดยในความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายคดีนี้ มีองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 15 วรรคสาม (2) ที่แก้ไขใหม่ ไม่เป็นคุณแก่จำเลยที่ 1 จึงต้องใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณตามมาตรา 15 วรรคหนึ่งเดิม มาใช้บังคับแก่คดีนี้ และความผิดฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนตามมาตรา 15 วรรคหนึ่งที่แก้ไขใหม่ มีองค์ประกอบความผิดเช่นเดียวกับมาตรา 15 วรรคหนึ่งเดิม จึงต้องใช้กฎหมายเดิมซึ่งใช้ในขณะกระทำความผิดมาบังคับแก่คดีนี้เช่นเดียวกัน ส่วนในมาตรา 66 วรรคสอง ที่แก้ไขใหม่ ซึ่งเป็นบทระวางโทษของความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนสำหรับเมทแอมเฟตามีนอันเป็นวัตถุแห่งการกระทำความผิดที่มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 375 มิลลิกรัมขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 กรัม แม้จะปรากฏว่าเมทแอมเฟตามีนของกลางคดีนี้มีจำนวน 46 เม็ด และมีน้ำหนักสุทธิเกินกว่า 1.5 กรัม ก็ตาม แต่ตามคำฟ้องไม่ปรากฏว่าเมทแอมเฟตามีนของกลาง คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้จำนวนเท่าใดกันแน่ จึงไม่อาจปรับบทลงโทษจำเลยที่ 1 ตามมาตรา 66 วรรคสอง ที่แก้ไขใหม่ได้ แต่ต้องถือว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 ยังเป็นความผิดอันต้องด้วยบทระวางโทษตามมาตรา 66 วรรคหนึ่ง ที่แก้ไขใหม่อยู่ ซึ่งตามมาตรา 66

วรรคหนึ่งที่แก้ไขใหม่ ในส่วนของโทษจำคุกมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 15 ปี แตกต่างจากมาตรา 66 วรรคหนึ่ง เดิม ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึงจำคุกตลอดชีวิต กฎหมายที่แก้ไขใหม่ในส่วนนี้เป็นคุณแก่จำเลยที่ 1 มากกว่ากฎหมายเดิม จึงต้องใช้กฎหมายที่แก้ไขใหม่ดังกล่าวในส่วนที่เป็นคุณมาบังคับแก้คดีนี้ตาม ป.อ. มาตรา 3 ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 1 ยังมิได้ยกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขให้ถูกต้อง จำเลยที่ 1 ย่อมมีสิทธิยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกาได้ แม้ว่าจะเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วแต่ในศาลอุทธรณ์ภาค 1 ก็ตาม ทั้งนี้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225 ศาลฎีกาจึงต้องแก้ไขโดยปรับบทลงโทษจำเลยที่ 1 ให้ถูกต้อง และเห็นสมควรแก้ไขกำหนดโทษจำคุกจำเลยที่ 1 เสียใหม่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบทกฎหมายที่แก้ไขใหม่ตามที่จำเลยที่ 1 ฎีกาด้วย และเนื่องจากจำเลยทั้งสามเป็นตัวการกระทำความผิดในคดีนี้ด้วยกัน ถือว่าเหตุดังกล่าวเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจพิพากษาแก้ไขตลอดไปถึงจำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งมิได้ฎีกาได้ด้วยตาม ป.วิ.อ. มาตรา 213 ประกอบมาตรา 225

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและฐานร่วมกันจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง (เดิม) และมาตรา 66 วรรคหนึ่ง (ที่แก้ไขใหม่) ประกอบ ป.อ. มาตรา 83 ให้ลงโทษฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุกคนละ 5 ปี ฐานร่วมกันจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน จำคุกคนละ 4 ปี คำให้การในชั้นจับกุมของจำเลยที่ 1 ที่รับว่าเป็นคนคอยดูต้นทาง นับว่าเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้จำเลยที่ 1 กระทั่งหนึ่งในห้า ตาม ป.อ. มาตรา 78 แล้ว คงจำคุกจำเลยที่ 1 สำหรับความผิดกระทงแรก 4 ปี และกระทงหลัง 3 ปี 2 เดือน 12 วัน รวมโทษเป็นจำคุกจำเลยที่ 1

มีกำหนด 7 ปี 2 เดือน 12 วัน จำคุกจำเลยที่ 2 และที่ 3 มีกำหนดคนละ 9 ปี
นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1.

(สุรชาติ บุญศิริพันธ์-กิตติศักดิ์ กิตติคุณไพโรจน์-กำธร โพธิ์สุวรรณกุล)

ศาลจังหวัดลพบุรี - นายวิชล วิมุตติสุข
ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายประสิทธิ์ สนามชวด

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>